

1500849-15.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500849-15.2021.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-15.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DANIEL MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ANDRÉ DANIEL MENDES, qualificado a fls. 17, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque no dia 13 de outubro de 2021, por volta de 15h20min, no cruzamento da Rua 14-B com a Rua C, bem como na residência localizada na Avenida 26-B nº 1.355, Bairro Residencial Taís II, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, para fins de tráfico, três porções

de maconha, bem como teria em depósito, com a mesma finalidade, dezesseis porções daquele entorpecente, com peso aproximado de 33 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a inicial que "policiais militares receberam a informação de que o denunciado estava traficando drogas na Rua 14-B com a Rua C, no bairro José Pugliesi, próximo à Associação de Judô, razão pela qual para lá se dirigiram, encontrando, ao chegarem, ANDRÉ. Na posse dele, os militares localizaram três porções de 'maconha', um celular e a quantia de oito reais.

Na sequência, os policiais foram à residência do denunciado e, autorizados por ele e por seu genitor, ingressaram no imóvel, localizando, no quarto de ANDRÉ, mais especificamente na gaveta de uma estante, outras dezesseis trouxas da mesma droga, a quantia de cinquenta reais e, ainda, uma folha contendo anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes."

A denúncia de fls. 76/78 foi recebida em 28 de outubro de 2021 (fls. 82/83). O Réu deu-se por citado, constituindo Defesa (fls. 96/97), apresentando defesa preliminar (fls. 101/114), rejeitada a fls. 124/125 por não ser hipótese de absolvição sumária. Durante a instrução, foi colhida prova oral, bem como interrogado o Réu (fls. 178/185 e 189/195).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 186/187).

A douta Defesa, por seu turno, afirmou a existência de contradições entre os depoimentos dos policiais e, de outro giro, seria o Réu usuário de entorpecentes, de modo que pediu a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 200/214).

É o relatório.

## II. Fundamento e DECIDO.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, no boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/11, auto de constatação provisória de fls. 12, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 80/81, guia de depósito de fls. 127, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria delitiva, de igual forma, foi comprovada. O Réu, em Juízo, negou o teor da acusação, sustentando que havia ido fazer um orçamento na Rua 14-B quando foi parado por policiais dizendo existir uma denúncia contra ele, sendo que encontraram dezenove porções de maconha em sua casa, enquanto aguardou do lado de fora, afirmando que a droga localizada era para seu próprio consumo e que somente carregava o telefone celular e dinheiro. Ademais, trabalha como pintor, faz uso de maconha e cocaína e parou, há alguns meses, de consumir crack, dizendo, por outro lado, que a anotação encontrada era porque comprova droga fiado com aquelas pessoas e, como tinha vendido um telefone celular, eles estavam descontando nas drogas e marcava para seu controle (fls. 191/195).

De absolvição não se pode falar.

O policial militar Lucas, em fls. 178/180, relatou que possuíam denúncia contra o Réu e na data dos fatos o encontraram parado em um conhecido ponto de venda de drogas, sendo abordado e com ele encontraram porções de entorpecente e dinheiro,

dirigindo-se para sua casa, porque constava daquela denúncia que ele guardava droga ali, sendo que no local foi autorizado o ingresso, permanecendo do lado de fora com o Acusado, ao passo que outros policiais encontraram mais entorpecente, dinheiro e anotações em seu quarto. Ademais, disse que ele era conhecido e acredita que não aparentava o Réu estar sob efeito de droga. Em linhas gerais, este também foi o conteúdo do depoimento do policial Bruno, em fls. 181/184, que ainda ressaltou que o Réu, ao avistar a viatura, aparentou nervosismo e na casa do Acusado localizaram mais dezesseis porções de maconha e uma folha de caderno, ao passo que, indagado, o Réu disse que era para seu consumo, porque usuário.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos. Maria das Dores, em fls. 184/185, disse ser vizinha do Réu, que ele é pintor, não é envolvido com criminalidade, tem filhos e que apesar de não tê-lo visto usar droga, que ele é usuário porque lhe conta, tampouco tendo visto movimento em sua casa. Do mesmo modo, Fernando, que disse que o Réu era seu sócio, trabalhava como pintor e que no dia dos fatos ele saiu para fazer um orçamento e não voltou, não sabendo dizer se ele usa entorpecente, afirmando que ele não vende, porque trabalha com o depoente (cf. fls. 189/190).

O depoimento prestado pelos policiais é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento dos militares, ao passo que não se observa contradições, ao contrário do que sustenta a douta Defesa. A condição funcional, de qualquer forma, não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse panorama, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos. Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Não se pode ignorar que os militares, enquanto agentes públicos, se limitaram a contar o ocorrido, nada sendo levantado e muito menos comprovado que indicasse não fosse verdadeiro seus depoimentos ou que de alguma maneira tivessem intenção em incriminar um inocente, de forma que viesse a colocar em xeque as declarações destas testemunhas.

Some-se a isso que o documento de fls. 11, arrecadado no quarto do Réu junto com parte da maconha apreendida, é de evidente ligação com o tráfico, tratando-se de anotação do movimento de venda de drogas pelo traficante, não o contrário como sustentou o Réu, porquanto, muito embora tenha sido lhe franqueada a possibilidade de robusta produção probatória, não fez ao menos início de prova de que tivesse vendido um telefone celular para comprar por droga, lembrando que ele foi apreendido justamente com seu celular.

Destarte, por todo o acima exposto, levando em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, a confirmação de ser o Réu conhecido dos meios policiais, ser encontrado em conhecido ponto de traficância, a anotação com clara ligação ao comércio de droga, indicam que no dia, horário e local apontados na denúncia, o Acusado trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente para

comercialização. Tais condutas apontam que ele utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, impedindo, deste modo, a desclassificação almejada pela douta Defesa em suas alegações finais, sendo que nem mesmo há prova de que fosse o Réu usuário de drogas, dada a declaração claudicante das testemunhas de defesa, ambas nunca tendo visto consumindo droga. De qualquer modo, o simples fato de ser usuário – sequer comprovado, repita-se - não exclui a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que, ao contrário do que sustenta o nobre defensor, “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado é portador de maus antecedentes. Contudo, deixo de majorar sua pena levando em consideração os antecedentes, para não provocar um bis in idem com a agravante da reincidência, de modo que, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, verifico que deve a pena-base ser fixada no piso legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação das condições financeiras do Acusado.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que o Réu é reincidente em crime doloso (cf. fls. 34, autos nº 0001687-37.2018.8.26.0210), demonstrando persistir na prática de condutas ilícitas, devendo, por isso, ser majorada a reprovação. Aumento sua pena, desta forma, em 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e a forma como se desenhou os fatos, acima mencionado, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, ainda que, concomitantemente, possua ocupação lícita (cf. fls. 189/190 e 214), que não é incompatível com a traficância.

Nesse diapasão: “Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução” (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo e ser o Réu reincidente, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo

do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III,

do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro junto com a droga, assim como telefone celular, evidenciando-se seu emprego na venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda do bem e dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu ANDRÉ DANIEL MENDES, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro e do telefone celular apreendido com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhem-se os objetos apreendidos com o Réu em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez e por sua reincidência Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois nada justifica que preso em flagrante, fosse colocado em liberdade depois de condenado por crime equiparado ao hediondo.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA